

1503737-65.2019.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico de drogas, oportunidade em que visualizou o acusado, conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, agachado, pegando um objeto no chão, próximo a um poste de iluminação, cercado por uma vegetação. Ao notar a presença da viatura, Heberth levantou-se e foi em direção ao menor Edwin. Em abordagem, foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503737-65.2019.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503737-65.2019.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 3816581 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 88/19/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2143004 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEBERTH PEREIRA AMORIM

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

HEBERTH PEREIRA AMORIM, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI da Lei n. 11.343/06. Consta na denúncia que no dia 8 de março de 2019, por volta das 9h15, na Rua Guarapari, 315, Conjunto Habitacional Gabriel Hernandez, nesta cidade e comarca de Catanduva/SP, o acusado guardava consigo drogas, juntamente com o adolescente EDWIN GABRIEL TORRES DE ANDRADE, consistentes em 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína e 399 (trezentos e noventa e nove) pinos de crack, a fim de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação acostado às fls. 12/14.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o denunciado e o adolescente EDWIN guardavam consigo as drogas mencionadas, para comércio com terceiros, quando foram surpreendidos por policiais

militares. Os policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pelo tráfico de drogas, quando notaram a presença do denunciado agachado próximo a um poste de iluminação em um local cercado por mato e o adolescente ao seu lado. Ao avistar a guarnição policial, o denunciado saiu andando rapidamente, sendo abordado em seguida. Em revista pessoal, com o denunciado foi encontrada a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) e com o adolescente R\$ 102,00 (cento e dois reais). No poste onde o denunciado estava agachado, os policiais encontraram 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína e 399 (trezentos e noventa e nove) pinos de crack dentro de um saco plástico. A circunstância da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias denotam que o objetivo do denunciado era o comércio ilícito.

Houve defesa preliminar (Fls. 48/52).

A denúncia foi recebida em 03 de abril de 2020, bem como designada audiência de instrução e julgamento (fl. 87).

No curso da instrução processual foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 192/196).

A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas com fundamento no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal e, se este não for o entendimento, que seja ABSOLVIDO nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devida inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação. (fls. 210/211).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

O policial militar A.A. DE. M disse que em patrulhamento de área, juntamente com Policial Militar Zavan, ao trafegarem com a viatura Policial pela Rua Guarapari, visualizou uma pessoa do sexo masculino, posteriormente identificada pelo nome Herbet, agachado próximo a um poste de iluminação, local cercado por mato. Ele, Herbet ao perceber a aproximação da viatura Policial, saiu rapidamente do local, indo ao encontro de outras pessoas ali próximo. O depoente realizou buscas no local, e localizou próximo ao local que Herbert estava agachado, 01 saco plástico contendo 399 pinos de crack e 59 pinos de cocaína. Em revista pessoal em Herbet, nada de ilícito foi encontrado, somente a quantia de R\$15,00 em dinheiro, em revista pessoal no adolescente Edwuin, foi encontrado a quantia de R\$102,00 em dinheiro, que não soube explicar a origem do dinheiro. O depoente relata que Herbert e Edwuin são conhecidos nos meios Policiais. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

O policial militar B.Z. F disse que em patrulhamento com o CB. PM. Amarildo, pela Rua Guarapari, visualizou uma pessoa do sexo masculino, posteriormente identificada pelo nome Herbet, agachado próximo a um poste de iluminação, e ele ao perceber a aproximação da viatura Policial, saiu rapidamente do local, indo ao encontro de outras pessoas. O depoente acompanhou as buscas, e visualizou quando o Policial Militar Amarildo, encontrou próximo ao local que Herbert estava agachado, 01 saco plástico contendo 399 pinos de crack e 59 pinos de cocaína. Na revista pessoal em Herbet, nada de ilícito foi encontrado, somente a quantia de R\$15,00 em dinheiro, no local também foi abordado Edwuin, com a quantia de R\$102,00 em dinheiro, que no local não soube explicar a origem da quantia em dinheiro. O local e as pessoas são conhecidas nos meios Policiais. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Interrogado, H.P. A disse que no dia de hoje, estava sentando na praça localizada na Rua Guarapari, juntamente com 8 pessoas. Nega a propriedade da droga localizada. Afirma que estava com a quantia de R\$15,00 que ganhou de um serviço no dia anterior. Afirma ser usuário de maconha e nega a venda de entorpecentes no local. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

O adolescente E. G. T. DE A disse que no dia de hoje, estava sentado em um banco nos prédios do Gabriel Hernandez, quando foi abordado por Policiais Militares. Estava com a quantia de R\$90,00 que havia ganhado de sua genitora para fazer compras no supermercado. Nega a propriedade da droga localizada, bem como nega a venda de entorpecentes no local, afirma ser usuário de maconha. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 6/7), pelo laudo de constatação (fls. 12/14), pelo exame químico e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

A busca pessoal exige fundada suspeita. O RHC 158580 / BA é bem ilustrativo:

“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”.

A excepcionalidade da conduta policial está fincada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa.

Observa-se que a busca pessoal não se aperfeiçoou apenas e tão somente em razão do tirocinio policial, mas também porque a conduta do acusado era suspeita, na medida em que estavam em local cujo tráfico é corrente, e tentou sair rapidamente do local ao avistar a viatura. Frise-se que em revista pessoal não foram encontrados entorpecentes, contudo, em busca pelo local onde o acusado estava foram encontradas as drogas indicadas na denúncia, o que justificou a medida.

De se concluir, assim, que não se tratou de medida ilegal e abusiva, sob o nefasto pretexto de averiguação discriminatória, motivo pelo qual se afasta a tese da ilegalidade.

No mais, houve a produção de prova em juízo.

A testemunha B.Z. F, policial militar, disse que, não se recorda muito da ocasião dos fatos. Mas se recorda que efetuava patrulhamento com o colega Amarildo, em local conhecido pelo tráfico de drogas, oportunidade em que visualizou o acusado, agachado mexendo em algo ao solo, próximo a um poste. Confirma que o réu estava com o adolescente. Aduziu que o modus operandi utilizado no local consiste em enterrar a droga e, posteriormente pegá-la para os clientes.

A testemunha A.A. De. M, policial militar, disse que, na ocasião dos fatos, efetuava patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico de drogas, oportunidade em que visualizou o acusado, conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, agachado, pegando um objeto no chão, próximo a um poste de iluminação, cercado por uma vegetação. Ao notar a presença da viatura, Heberth levantou-se e foi em direção ao menor Edwin. Em abordagem, foram localizados a quantia de R\$15,00 (quinze reais) com o réu e, na posse do menor encontrou a quantia de R\$102,00 (cento e dois reais). Em vistoria pelo local, onde o réu estava, foram encontrados, em um saco plástico, 399 (trezentos e noventa e nove) pinos de crack e 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína. Não se recorda da versão do réu dada na ocasião. Disse que estava uns 20 metros de distância quando avistou o réu. Disse que só estava o Heberth abaixado ao poste, em que pese haja bastante fluxo entrando e saindo ali no condomínio. Não visualizou o acusado entregando entorpecentes. Confirmou que o menor era conhecido dos seus policiais, não se recordando do conteúdo das versões deles na ocasião. Disse que ele estaria na posição agachado claramente de pegando ou escondendo alguma coisa.

A testemunha E. G. T. De. A disse que, na ocasião dos fatos, sua mãe pediu para ir ao mercado. Não tinha o que ela pediu para comprar. Em seguida, avistou seus amigos começou a jogar futebol com seus colegas, quando foi buscar uma bola perto dos

prédios. Ficou esperando perto da praça o objeto junto com o Herberth, ocasião em que os policiais militares encontraram drogas, perto de um poste e os conduziram até a delegacia. Aduziu que em momento algum notou o réu com drogas. No mais, informou que já foi processado por tráfico de entorpecentes, sendo a terceira vez que foi apreendido.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Em breve síntese, a versão dos policiais é uníssona e apontou que o acusado e o adolescente se encontravam juntos em ponto de traficância corrente tendo, o réu, sido avistado em atitude suspeita, porquanto agachado e claramente pegando ou escondendo algo em poste de iluminação cercado de mato. Neste mesmo local e ocasião foram encontrados 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína e 399 (trezentos e noventa e nove) pinos de crack, certo ainda que, segundo o depoimento de um dos policiais, enterrar a droga naquele local é modus operandi bastante utilizado pelos traficantes daquela região.

Também ficou confirmado por um dos depoimentos que o acusado é conhecido dos meios policiais. A testemunha também confirmou que avistou apenas duas pessoas, além de outras decorrentes do fluxo de entrada e saída dos "predinhos", infirmando assim a alegação de que o acusado estaria com mais 8 pessoas apenas bebendo.

A versão apresentada pelo menor Edwin ficou isolada nos autos, sobretudo porque distoa em parte com a versão apresentada em solo policial.

Quanto ao artigo art. 40, VI, da Lei 11.343/06: "Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe. Justifica-se o recrudesimento pela maior vulnerabilidade desses indivíduos, suscetíveis ao consumo de entorpecentes ou à cooptação para o exercício do comércio malsão, tendo em vista a reduzida capacidade de discernimento, a inimputabilidade e a particular condição biológica, psíquica, moral e de caráter, ainda em fase prefacial de formação." (HC n. 411.340/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 26/2/2018).

Veja que o tipo em comento destaca os verbos envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, independentemente de anterior corrupção do menor, visto que se a intenção for esta, estar-se-ia diante do tipo descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, cujos verbos são corromper ou facilitar a corrupção.

Para ilustrar: "Para a configuração da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, não importa se o adolescente envolvido na prática da mercancia ilícita não era neófito no mundo do crime". (AgRg no HC 739533 / SP).

Como a descrição típica é claramente formal, basta a participação da criança ou do adolescente para a sua incidência, o que restou demonstrado nos autos.

Demais disso, "A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio" (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010)

A quantidade de droga 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína e 399 (trezentos e noventa e nove) não denotam a finalidade de mero consumo próprio, em especial pela forma como estavam acondicionadas e pelo local em que encontradas.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas. Parte-se das circunstâncias judiciais. A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes. A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

A quantidade de entorpecente apreendido é o bastante para a configuração do delito, mas não para a majoração da pena nessa fase.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e agravante.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar da pena base.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

No caso, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. É que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há fundadas notícias de que ela se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Quanto ao redutor de pena, tenho que a quantidade de droga destoa da normalidade, contudo o contexto dos autos não revelou habitualidade delituosa, pelo que aplico o redutor em seu patamar intermediário, justificando a diminuição da pena no quantum de 1/2.

Dessa forma, fixo em 2 anos e 06 meses de reclusão.

Presente ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Desse modo, aumento a pena de 1/6, tornando-a definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico. Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016). As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 500 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. Como a pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente em crime doloso e estão preenchidas as circunstâncias judiciais, como acima apontadas, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Da pena substitutiva aplicada: Dentro do rol exaustivo previsto no art. 43 do Código Penal, aplicando-se analogicamente o entendimento pacificado no Egrégio

Superior Tribunal de Justiça para a definição do quantum de aumento da pena base, a escolha justificada da pena restritiva de direitos está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Bem por isso, reputo suficiente a aplicação da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, como forma de retribuir à sociedade os danos provocados, reinserindo o sentenciado à comunidade, pelo mesmo tempo da pena aplicada, observando-se o disposto no art. 46 do Código Penal, que será individualizada no Juízo das Execuções Criminais.

E prestação pecuniária no valor de 03 salário-mínimo, com nítido caráter reparador, que melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, vez que a substituição ocorrida lhe é mais favorável.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado HEBERTH PEREIRA AMORIM, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput e § 4º da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 500 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. Entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade por igual período (02 ano e 11 meses) e outra de prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo em favor de entidade com destinação social, nos termos do art. 44 c/c art. 45, § 1º e art. 46 do Código Penal.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Arbitro honorários para o(a) advogado(a) indicado(a) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Oportunamente, expeça-se certidão.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos (arts. 63-C e 63-D da Lei 11.343/06).

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA